

1501869-93.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... uma quantia em dinheiro por dia no tráfico. Afirmou que não se recordava o nome do fornecedor das drogas. Informou que já havia "respondido" por tráfico e receptação, e que estava desempregado e sem renda fixa lícita.

Em juízo, confessou o tráfico, informando que foi obrigado a trabalhar, porque estava devendo dinheiro (comprou drogas "fiado") por ser usuário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501869-93.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501869-93.2022.8.26.0537 Controle nº 1412/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE WELHINTON CABOCLO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOSE WELHINTON CABOCLO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 04 de setembro de 2022, na Rua Bethoven, altura do número 106, Bairro Jardim Casa Grande, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 33/36).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 62/63), sendo recebida a denúncia em 19.10.22 (fls. 67/68). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência específica, que seja considerada a confissão nas duas fases, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º por ser reincidente específico e fixação de regime fechado.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, que seja fixada a pena no mínimo legal, compensada a reincidência com a confissão judicial, aplicação do art. 33, §4.º, a fixação de regime aberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 07), o acusado confessou a prática do crime, dizendo que receberia uma quantia em dinheiro por dia no tráfico. Afirmou que não se recordava o nome do fornecedor das drogas. Informou que já havia "respondido" por tráfico e receptação, e que estava desempregado e sem renda fixa lícita.

Em juízo, confessou o tráfico, informando que foi obrigado a trabalhar, porque estava devendo dinheiro (comprou drogas "fiado") por ser usuário de "crack".

Trabalhava como ajudante de cozinha. Tem outro processo por tráfico, mas não sabe o andamento.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 05/06), relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde costumeiramente há denúncias de tráfico, quando avistaram o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Narraram que em busca pessoal não localizaram nada de ilícito com o réu, que, inicialmente, disse que estava no local para consumir maconha, mas depois confessou o tráfico. Disseram que o réu informou que guardava as drogas em uma sacola plástica, debaixo de um caminhão estacionado na via pública, a cerca de 4 metros de onde estavam. Afirmaram que localizaram a sacola plástica e no interior desta encontraram porções individualizadas de maconha, cocaína e "crack".

Kevin (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto tráfico, que viram o réu parado e abordaram, o qual confessou o tráfico. Afirmou que a droga foi apreendida junto a um caminhão. Havia denúncia que as drogas estavam escondidas junto ao caminhão e as roupas do traficante. O réu estava próximo ao caminhão e depois que acharam as drogas o mesmo confessou. Inicialmente o réu disse que era usuário. As drogas estavam divididas em porções, prontas para a venda. Acha que ele fez a busca pessoal e o outro policial que localizou as drogas. Não se lembrou a quantidade total de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Cléber. Informou que acharam as drogas junto ao caminhão em razão de denúncia anônima informar que estaria nesse local. As drogas estavam divididas em porções. Não conhecia o réu anteriormente. O réu estava parado junto ao caminhão. Inicialmente o réu falou que estava no local só usando maconha, mas depois confessou. Não se lembra se tinha dinheiro, só que o réu falou que tinha acabado de iniciar o turno e receber as drogas.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade (fls. 25 - 45 porções de maconha, 36 papelotes de cocaína e 29 pedras de "crack") e variedade (maconha, cocaína e "crack") de drogas apreendidas, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estavam divididas em invólucros, bem como as confissões extrajudicial e judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de ter em depósito e guardar, pelo que caracterizado o

crime.

Em relação à alegação da defesa de que não foi apreendido dinheiro, isso não inocenta o réu, posto que é fato público e notório que há o "recolhe" e ainda diante da informação do policial Cleber, que falou que tinha acabado de iniciar o turno e receber as drogas.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 22/24) e laudo definitivo (fls. 77/79).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente específico (fls. 89/90 - proc. 1500139-43.2018).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (45 porções de maconha, 36 papérolas de cocaína e 29 pedras de "crack"), já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e as confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESp N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 89/90 – proc. 1500139-43.2018), sequer provou possuir ocupação lícita, demonstrando que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 04.09.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 03.01.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JOSÉ WELHINTON CABOCLLO DA SILVA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Em relação ao papel com anotações manuscritas, apreendido (fls. 25) e já periciado (fls. 80/82), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminado.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 38) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 10 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA